

1500261-37.2020.8.26.0632

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... averbou que o réu não praticou o tráfico de entorpecentes, pontuando, a sua vez, que o réu era usuário de drogas e, ainda, que praticou a venda de entorpecente com a finalidade de se obter dinheiro para a aquisição de cocaína para uso próprio. Pugnou, a sua vez, pela desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de drogas, previsto no art.28 da Lei nº 11.343/06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

1ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500261-37.2020.8.26.0632 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500261-37.2020.8.26.0632

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2270089/2020 - 01º D.P. JALES, 14425929 - 01º D.P. JALES, 3896/20/227 - 01º D.P. JALES, 2270089 - 01º D.P. JALES

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

VINICIUS DAGOANI DE CARVALHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS

Vistos.

VINICIUS DAGOANI DE CARVALHO foi denunciado como incurso no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porquanto, em conformidade com os termos vertidos na exordial acusatória, no dia 30 de outubro de 2020, por volta das 18h45, na Rua Um, Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca de Jales/SP, nas imediações de estabelecimentos de ensino e igrejas, o réu trazia consigo, tinha em depósito e guardava para fins de entrega para consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de Cannabis Sativa L ("maconha"), com peso bruto de 51,35g, sendo que, em dado momento, de fato vendeu uma porção de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo os termos vazados na incoativa, na data dos fatos, o réu estava em sua residência e mantinha em depósito algumas porções de maconha com a finalidade de

comercializá-las, estando a droga embalada e pronta para entrega a consumo de terceiros.

Colhe-se, ainda, da prefacial acusatória, que o réu, através de mensagens telefônicas, negociou a venda de drogas com o usuário Paulo Cezar e, por este motivo, o usuário se dirigiu até a residência do réu, ocasião em que ele vendeu uma porção de maconha a Paulo Cezar.

Perlustra-se, outrossim, da peça incoativa, que policiais realizavam patrulhamento de rotina e avistaram a prática delituosa, e, por sua vez, ao notar a aproximação da viatura, o usuário presente no local empreendeu fuga, sendo abordado pelos policiais, ocasião em que informou que estava no local para adquirir drogas do réu, tendo efetuado o pagamento da quantia de R\$ 30,00 por uma porção de maconha.

Colhe-se, em adição, da prefacial acusatória, que, ato contínuo, o réu foi abordado e, em sua posse, foi encontrada uma porção de maconha devidamente embalada, bem como a quantia de R\$ 30,00, em notas diversas, além de um aparelho celular.

Consta da prefacial, por sua vez, que, diante da situação flagrancial, foi franqueada a entrada dos policiais no imóvel, quando, durante as buscas, foram localizadas no quarto do réu outras três porções de maconha, embaladas em uma sacola plástica azul, idênticas à porção comercializada e, ainda, àquela apreendida na posse dele.

Perlustra-se, outrossim, da denúncia, que foi encontrada a quantia de R\$ 21,30, em notas diversas, e outro aparelho celular, sendo dada a voz de prisão ao réu.

Divisa-se, em adição, nas letras insculpidas na denúncia, que o réu se dedicava à traficância, valendo-se da situação estratégica do imóvel, que fica nas imediações da "Escola Municipal Profª. Elza Pirro Viana" e da "Igreja Plena Paz".

Eis, em compêndio, os termos da denúncia (fls.138/141).

O réu foi notificado dos termos da denúncia (fls.158), de sorte que, no comenos oportuno, por intermédio do seu defensor, ofereceu a abalizada defesa preliminar (fls.164/165).

Nada obstante, sem embargo do esmero da defesa, a denúncia acabou sendo recebida em 18 de janeiro de 2021 (fls.166/167).

Na data aprazada, houve a colheita da prova oral, ouvindo-se, na oportunidade, uma testemunha de acusação, tendo em vista o quadro de saúde de outra testemunha arrolada pela acusação, indo a óbito posteriormente (fls.211). O réu, por sua vez, foi ouvido em sede de interrogatório, por intermédio do qual exerceu a sua autodefesa (fls.204/206 e 317/319).

Ao cobro da instrução, primeiramente, como sói ocorrer, manifestou-se o Ministério Público, na lavra de seu Ilustre Promotor de Justiça, o qual, em sua faina, pugnou pelo acolhimento da pretensão acusatória, averbando, no ponto, a comprovação da materialidade pelo auto de exibição e apreensão (fls.13/14); laudo de constatação (fls.23/26) e exame definitivo químico-toxicológico (fls.152/154); laudo sobre o celular apreendido (fls.124/127); além da prova oral coligida em audiência, bem como a comprovação da autoria do delito imputado amparada pelos elementos colhidos nos autos.

Ao incursionar sobre a dosimetria da pena, no que alude à pena base, pugnou, no ponto, que o réu possui personalidade voltada à prática de ilícitos. De sua vez, na segunda fase, manifestou-se pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Por derradeiro, na terceira fase, manifestou-se pela causa de aumento

contida no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, tendo em vista que o crime foi praticado nas imediações de uma escola e de uma igreja.

Pontuou, em adição, que deve ser afastada a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão das representações por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, furto qualificado, desacato e ameaça, em que houve condenação, e, ainda, que o réu se dedicava à atividade criminosa desde sua adolescência.

Em linha de remate, propugnou pela fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.258/273).

A defesa, por seu turno, averbou que o réu não praticou o tráfico de entorpecentes, pontuando, a sua vez, que o réu era usuário de drogas e, ainda, que praticou a venda de entorpecente com a finalidade de se obter dinheiro para a aquisição de cocaína para uso próprio. Pugnou, a sua vez, pela desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de drogas, previsto no art.28 da Lei nº 11.343/06 ou, ainda, pelo reconhecimento do crime previsto no art.33, §3º, da Lei de Drogas.

Pugnou, ao final, na fixação da dosimetria, pela pena mínima na primeira fase, considerando a primariedade do réu e a ausência de maus antecedentes. Na segunda fase, pela ausência de agravantes ou atenuantes da pena. Na terceira fase, pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art.33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo (fls.320/322).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece parcial acolhimento.

Da acendrada análise do arquétipo probatório, colhe-se, em compêndio, que, em pretório, a testemunha Gilson Evangelista Maciel, ao prestar seu depoimento em juízo, disse que atuou na diligência relativa ao fato, juntamente com o cabo Dácia. Relatou, por sua vez, que, ao contornarem uma esquina, avistaram um movimento de tráfico, com entrega e recebimento de algo, afirmando, ainda, que o indivíduo se evadiu com uma motocicleta ao notar a presença da viatura policial. Disse, ainda, que conseguiram fazer a abordagem do réu, que foi ao encontro dos policiais, sem resistência. Afirmou, a seu turno, que, a respeito da droga, o réu declarou que uma pessoa havia passado o contato para comprar droga e que o contato do réu foi indicado. Disse, em acréscimo, que existem mensagens de celular contendo conversas sobre a negociação da maconha. Disse, ainda, que o indivíduo que vendeu a droga confessou a propriedade da droga e o valor do entorpecente que tinha sido entregue. Confirmou, a sua vez, que, na data do fato, o comprador da droga havia confessado a recente aquisição da droga do réu por R\$30,00, e, outrossim, que esta quantia foi encontrada com o réu. Confirmou, ainda, que o comprador da droga confessou ter feito contato com o réu para a aquisição da droga pelo aplicativo WhatsApp e, por sua vez, que o comprador tinha ido ao local para buscar a droga. Confirmou, outrossim, que foram localizados mais entorpecentes na residência do réu, além da droga encontrada na posse dele, afirmando, a seu turno, que o próprio réu indicou a localização destes entorpecentes, ressaltando, a sua vez, que o genitor do réu também residia ou trabalhava no local. Disse, por sua vez, que desconhece passagens do réu pela polícia, informando, outrossim, que a polícia civil tinha denúncias dele sobre a prática do tráfico de drogas no local. Disse, ainda, que não se recorda se o réu era antigo morador da cidade de Jales ou se veio de outro município. Afirmou, por sua vez, que o réu morava em frente de uma escola estadual, chamada Elza Pirro Viana, e que estava fazendo a entrega do entorpecente na calçada desta escola, afirmando, outrossim, que existe uma igreja nas proximidades. Relatou, em adição, que a escola fica situada em uma rua que faz ligação com a avenida principal da cidade, bem como com o sistema de transporte público. Afirmou,

por sua vez, que a escola estava fechada, em razão da pandemia. Confirmou, a seu turno, que as tratativas para a aquisição do entorpecente ocorreram por aplicativo de celular, confirmando, ainda, que o réu já havia feito a negociação em momento anterior, estando na calçada da escola para a entrega do entorpecente e recebimento do pagamento. Disse, ainda, que não se recorda se o comprador realizou aquisições de entorpecentes anteriores com o mesmo réu. Relatou, a seu turno, que não se recorda da justificativa apresentada pelo réu para a comercialização da droga. Relatou, ainda, que, na residência, notou a existência de um suporte de trabalho do genitor ao réu e, outrossim, que o pai dele não quis se envolver no fato, percebendo uma atitude de quem tem cumprido seu dever paterno.

O réu Vinicius Dagoani de Carvalho, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, disse que tem 20 anos de idade, que não concluiu o estudo colegial, que trabalha na companhia do seu genitor, morando juntos e, ainda, que a sua mãe é falecida. Confirmou, a seu turno, que já sofreu ação socioeducativa. Confessou, por sua vez, o fato imputado, quanto à entrega do entorpecente em local próximo da sua residência, negando, de outro bordo, a existência da droga encontrada em sua residência. Disse, em acréscimo, que era usuário de droga e que apenas existiam restos de entorpecente em sua casa. Confessou, a seu turno, o encontro da droga em sua posse durante a abordagem policial, confirmando, por sua vez, que os policiais abordaram o indivíduo que conduzia uma moto e que fez a aquisição do entorpecente, e, ainda, que foi abordado em seguida. Afirmou, ainda, que o comprador da droga pagou R\$30,00 pelo entorpecente, não se recordando da quantidade aproximada da droga vendida. Negou, por sua vez, que tivesse a quantidade de 50g de maconha em sua casa, afirmando, ainda, que era usuário de droga e que apenas mantinha em sua residência uma quantidade suficiente para fumar. Disse, em adição, que vendeu o entorpecente porque estava sem dinheiro no final do mês e, ainda, que o valor da venda seria complementado para a aquisição de sua outra droga, a cocaína, para o seu consumo. Confirmou, ainda, que os policiais ingressaram em sua residência, confirmando, outrossim, que houve a apreensão de droga em sua casa, negando, a seu turno, a quantidade mencionada na Denúncia. Disse, em adição, que somente existiam farelos de entorpecente em sua residência, afirmando, ainda, que não os escondia. Afirmou, a seu turno, que a pessoa que fez a aquisição da droga era conhecida.

Em apertada síntese, os parágrafos encimados espelham os contornos da prova oral.

A pretensão acusatória, no caso vertente, merece ser parcialmente albergada.

No caso em tela, a quadra probante suporta o reconhecimento de que as drogas apreendidas eram destinadas ao tráfico.

De partida, de ver-se que, no caso vertente, despontou como indisputável o fato de o réu ter promovido a tradição da droga, mediante contraprestação.

Demais disso, os diálogos que estão registrados no aparelho de telefonia móvel, a rigor, suportam, à saciedade, o desiderato de mercancia.

Carrego, em adição, que, no caso em tablado, o réu confessou a venda, apresentando, tão somente, versão divergente sobre a quantidade da droga, o que, a rigor, diante da prova colhida nestes autos, se torna circunstância periférica para o reconhecimento do tráfico.

Conquanto não haja a sobrepujança dos depoimentos dos policiais, até porque não adotamos o sistema tarifário, não havendo supremacia de determinadas provas sobre outras, tendo todas valor relativo, a pedra de toque no caso em comento diz com o fato de o arcabouço probatório ter se mostrado coeso e convincente no que atine ao fato de que as drogas apreendidas eram destinadas à mercancia.

A materialidade revelou-se inconcussa, conforme se colhe do laudo de constatação (fls.23/26), do laudo definitivo toxicológico (fls.152/154), bem como das mensagens

obtidas do celular apreendido do réu (fls.124/127), além da prova oral colhida em juízo.

De sua vez, a autoria, conforme gizado, ao nosso visto, revelou-se alvejante, seja pela dinâmica envolvendo a prisão do réu, como, também, pelas mensagens colhidas, as quais arredam quaisquer dúvidas sobre o envolvimento do réu com a mercancia de drogas, bem como sobre a circunstância de que, de fato, houve a venda da droga apreendida por ocasião do flagrante.

Em linha de remate, para além do mosaico probatório ser assaz suficiente à configuração do tráfico, não cabe o olvido de que, em audiência, o réu confessou a venda da droga.

De resto, calha trazer à calva algumas ponderações que tocam à dosimetria da pena:

Sem embargo do respeito tributado aos argumentos divergentes, merece averbação, por oportuno, que, a nosso visto, não se cogita da valoração negativa da conduta social ou da personalidade do réu.

Impende salientar, por pertinente, que, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, o ser humano não pode ser julgado por sua interioridade, ou, ainda, por aquilo que é ou representa ser, sob pena de configuração do Direito Penal do Autor, podendo, tão somente, ser julgado pelo fato decorrente de sua conduta.

Demais disso, diante da alteridade, numa sociedade plural, marcada pelo conflito, pela diversidade de valores, crenças, histórias e realidades, não se cogita da imposição de um padrão de comportamento, de molde que a análise da conduta do réu deve ficar circunscrita à figura típica, não sendo possível valorar negativamente o seu comportamento com base em padrões morais estabelecidos, tendo-se em conta a secularização, alteridade, pluralidade e laicização do Estado Democrático de Direito.

Por sua vez, para além da absoluta impossibilidade de eventual avaliação processual acerca da conduta social do réu e de sua personalidade, tendo-se em conta o fugaz contato existente com este, invariavelmente, restrita ao ato do interrogatório, mister considerar que eventual responsabilização somente poderá advir do fato imputado, caso provado, e, em absoluto, de eventual representatividade subjetiva que se faz de sua pessoa.

Como cediço, invariavelmente, imputações negativas acerca da conduta social, ou, ainda, de sua personalidade, não vêm lastreadas em qualquer substrato probatório, despontando, assim, como argumentos incontornáveis e sem possibilidade de refutação empírica, na medida em que afirmada a conduta social desviante, ou, a seu turno, a personalidade voltada para o crime, que sequer são objeto de debates no processo, não há como o réu provar o contrário.

Por sua vez, registros pretéritos não podem ser considerados para fins de valoração da conduta social ou personalidade voltada ao crime, sob pena de essencialização do ser humano, reduzindo-o a um ou poucos comportamentos problemáticos, olvidando-se da complexidade e da largura da existência de qualquer homem.

Em uma palavra, por evidente, a espessura de um ser não pode ser reduzida a um tipo penal.

Por sua vez, inconceito valorar, negativamente, eventuais experiências com atos infracionais, seja por marcar momento distinto da vida, a saber, da pessoa em desenvolvimento, - com menor capacidade de compreensão dos atos e, sobretudo, com menor capacidade de controle de suas emoções, observando-se, outrossim, que a valoração dos atos infracionais, no momento da fixação da pena para fins da exasperação, por via oblíqua, importa em transmudar a natureza do ato infracional, valorando-o como pena, na medida em que, ontologicamente, importará em um plus no

quantum de pena, e, portanto, no espectro temporal do cumprimento de pena, com privação de liberdade, ou, ainda, com restrição de direitos.

Em sentido homólogo, a jurisprudência de alto coturno.

“Conforme o entendimento firmado no âmbito na Terceira Seção, a prática de ato infracional não justifica a exasperação da pena-base, por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu a título de antecedentes, personalidade ou conduta social. Precedente.” (HC 364.532/SP, j. 07/12/2017).”

Averbe-se, em adição, que a valoração da personalidade, ontologicamente, avizinha-se da criminologia pautada no positivismo ortodoxo fundado na periculosidade, olvidando-se que a periculosidade está relacionada aos inimputáveis e não aos imputáveis.

Demais disso, ao passar em revista às análises da psiquiatria, psicologia e psicanálise, divisa-se, a rigor, a inexistência de significado unívoco acerca da personalidade, cabendo, ainda, salientar, por ocupar praça relevante, que, a rigor, a personalidade não se trata de uma análise que dimanar da ciência jurídica, mas, ao reverso, de outras ciências como a psiquiatria, a psicologia e antropologia, não podendo, em absoluto, decorrer de uma análise calcada em eventuais registros desabonadores, sob pena de ser esvaziado o seu sentido atribuído pelas ciências que, de fato, acabam por se debruçar sobre o tema.

Por sua vez, para valoração negativa da personalidade, a rigor, seria necessário a demonstração dos métodos e critérios científicos utilizados para a sua valoração, sob pena de impedir qualquer refutabilidade, violando, assim, a ampla defesa.

Em uma palavra, a análise da personalidade não pode dimanar de eventuais registros desabonadores, como, também, não se encontra autorizada se falecem dados metodológicos e científicos que permitam a sua aferição.

Com efeito, os argumentos devem ser verificáveis, por intermédio de dados objetivos, com a indicação dos métodos e critérios estabelecidos para análise, demonstrando-se, à saciedade, a base empírica utilizada ou sopesada para suportar a personalidade ou a conduta social com valoração negativa.

De sua vez, a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, no caso em tablado, a saber, os locais que merecem maior proteção, devem ingressar na esfera de conhecimento do réu, havendo adesão volitiva, tendo-se em conta o princípio da culpabilidade, sob pena de responsabilização objetiva.

Nessa quadra, diante da ausência de qualquer halo de provas de eventual correlação entre a traficância e os locais eleitos para maior proteção, não se cogita da incidência da majorante.

Fincadas a materialidade e autoria do delito, de ver-se que, no caso em tablado, nada há nada há a interditar a incidência da minorante preconizada no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Com efeito, passando em revista aos antecedentes (fls.198/203), divisa-se, à luz dos cânones constitucionais, que o réu não desponta como reincidente e, ademais, não ostenta maus antecedentes.

De outro bordo, sobranceiro destacar que, em verdade, não há a mais parca quadra indiciária a denotar o envolvimento do réu com organizações criminosas, na medida em que não se colhem dos autos sentença condenatória transitada em julgado por associação ao tráfico, ou, ainda, por associação criminosa (fls.198/203).

Nessa senda, a fixação do quantum da pena, bem como o estabelecimento do regime inicial da execução da pena, deverá observar os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade humana.

Averbo, no ponto, que o regime fechado, diante do cenário dessocializador do cárcere, que, como regra, somente serve à inocuização do ser humano, a rigor, deve ser reservado somente àqueles que praticam crimes timbrados pela violência à pessoa, notadamente aqueles matizados pela selvageria e barbárie, ou, ainda, àqueles que estão enfronhados nas grandes organizações criminosas, ou, ainda, diante de circunstâncias e formas do cometimento do crime que trazem conotações de maior gravidade que o padrão médio previsto para o tipo penal, como, verbi gratia, apreensão de expressiva quantidade de drogas e ou armamentos, em escala industrial, e outras situações quejandas denotativas de maior gravidade concreta.

Salvante tais cenários, sempre que possível, devem ser buscadas as penas alternativas, que, em essência, arredam os efeitos traumáticos e estigmatizantes do cárcere, os quais marcam, de forma deletéria e indelével a existência humana, sobretudo em razão do hiato existente entre o discurso da ressocialização e a realidade empírica e científica, ou, ainda, os regimes mais brandos, quando não preenchidos os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à concessão da suspensão condicional da execução da pena.

De fato, a prisionização invariavelmente, conduz à aculturação prisional, com regras deletérias e próprias de sobrevivência, marcadas, amiúde, pela violência e a malandragem.

Nesse sentido, acerca da crise do sistema penitenciário e da execução da pena, pontifica Juarez Cirino dos Santos, que: "(...) a prisão só ensina viver na prisão (...)" Direito Penal Parte Geral, 8ª Edição, p.477, tirant lo blanch.

Com efeito, iniludivelmente, hodiernamente, a estrutura prisional não cumpre com a promessa de ressocialização do ser humano, de molde que, as funções da pena, em verdade, acabam se restringido a uma única função, a saber, prevenção especial negativa, no sentido de neutralização do ser humano.

Nessa senda, o regime fechado deve ser destinado àqueles que, realmente, precisam ser neutralizados sob pena de grave risco social.

Assim, a apropriação legal do tempo e do espaço de determinada pessoa, no regime fechado, revela-se medida excepcional, que, diante da ausência do cumprimento integral das funções da pena, não deve ser prodigalizada, restringindo-se a cenários excepcionais.

Em uma palavra, imperiosa a análise do Direito Penal, em conjunto com a Criminologia e a realidade social e prisional, sob pena de as operações alusivas à aplicação da pena ocorrerem como mero exercício de subsunção, estabelecendo-se um verdadeiro sistema autopoiético, impenetrável por outras ciências.

Enfrentados os pontos nodais que ferem o mérito, passo, doravante, à dosimetria da pena, louvando-me, para tanto, do sistema trifásico.

Passando em revista aos termos do art. 59 do Código Penal c.c. o art. 42 da Lei 11.343/2006, não diviso qualquer circunstância digna de nota, a justificar o afastamento da pena base da baliza mínima contida no preceito secundário. De fato, o réu não ostenta, na ótica da leitura constitucional, eventuais registros desabonadores que possam ser considerados como maus antecedentes. Ademais, no que atine às demais circunstâncias judiciais nada há a ser considerado. Deveras, à falta do suporte probatório mínimo nada há a ser levado em consideração no que

alude à personalidade do réu, tampouco no que toca às circunstâncias e consequências do crime. Por seu turno, no mesmo viés, nada a ser considerado no que alude aos motivos do crime e à sua conduta social. Em linha de remate, averbo, porquanto oportuno, que a quantidade e a natureza da droga apreendida serão consideradas por ocasião da análise da causa de diminuição da pena, preconizada no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, evitando-se, com isso, a configuração do malsinado bis in idem. Nesse toar, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, atribuindo-se a cada dia multa o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, considerando-se, para tanto, a ausência de elementos que digam com a maior capacidade econômica por parte do réu.

Na segunda fase da dosimetria da pena, nada há a ser considerado. Com efeito, tendo sido a pena base fixada em seu patamar mínimo, não se cogita da possibilidade da incidência das atenuantes dimanadas da menoridade relativa e da confissão, não sendo possível, como regra, a redução da pena abaixo de seu patamar mínimo (súmula 231 STJ).

Nessa senda, tendo a pena base permanecido inalterada, na fixação da pena provisória, deverá ser observada a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste eito, a pena provisória deverá ser mantida no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

A seu turno, na terceira e última fase do sistema trifásico, diviso a presença da minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006. O predito reconhecimento dimana do fato de o réu ser primário, não havendo elementos a suportar a crença de que se dedica à atividade criminosa, à míngua de antecedentes desabonadores que suportem esta realidade.

A outro giro, nada há a indicar o seu envolvimento com organizações criminosas, porquanto jamais foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, tampouco pelo crime de associação criminosa, falecendo qualquer dado objetivo e digno de consideração a suportar dita realidade, o que não pode ser presumido dentro de um Estado Democrático de Direito que prima pelas garantias individuais de qualquer ser humano.

No caso vertente, diante da diminuta quantidade de droga apreendida, considerando-se a sua massa líquida (fls.23/26), de rigor a redução máxima preconizada na Lei de Drogas.

Deveras, o peso bruto corresponde ao peso do produto somado ao peso da embalagem, enquanto, diversamente, o peso líquido é o peso apenas da droga em si, razão pela qual, é o que deve ser considerado para fins de análise do aspecto quantitativo.

Em assim sendo, a redução preconizada deverá ocorrer, no patamar de 2/3, de molde a se fixar a pena definitiva em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de pena deverá ser fixado em conformidade com o quantum de pena fixado, considerando-se, outrossim, a primariedade do agente, como, também, as circunstâncias judiciais favoráveis.

Deveras, a imposição do regime fechado, de forma rígida, sem qualquer ponderação casuística, aos condenados a penas mínimas, não reincidentes e que não ostentam maus antecedentes, colide, integralmente, com os cânones constitucionais, mormente com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade humana.

Desta feita, no caso em tela, à força da pena fixada, sendo o réu primário, e não ostentando circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a título de cumprimento inicial de pena o regime aberto.

No que alude à interdição de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, em razão do quanto estatuído no art. 44 da Lei em testilha, mister considerar que, em verdade, a proscrição restou espancada pelo Supremo Tribunal Federal.

Demais disso, o Senado Federal, em 15 de fevereiro de 2012, editou a Resolução 5/2012, para riscar da Lei 11.343/2006, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”.

De fato, não se nega que, no exercício de sua função primaz, o legislativo possa engendrar sistemas mais recrudescidos para apenar aqueles que praticam determinados crimes.

Contudo, visando preservar a separação das funções, em hipótese alguma, é possível alijar do judiciário a possibilidade de análise de cada caso, atentando para os seus contornos individualizantes.

A leitura engessada é sempre indesejável, porquanto, em última análise, acaba por nivelar situações que não são parelhas.

Nessa linha de intelecção, não há qualquer tibieza em não se equipar situações que, de fato, não se afiguram paritárias.

Nessa senda, conclui-se que, indubiosamente, a melhor hermenêutica é de índole casuística, arredando-se, assim, fórmulas totalizantes, que desconhecem as variantes que circundam os diversos aspectos da vida humana, sob pena de se igualar cenários diametralmente opostos, dispensando-se o mesmo tratamento a qualquer pessoa alcunhada de traficante, ferindo-se de morte a individualização da pena.

Nesse trilhar, merece loas o posicionamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, descortinando a possibilidade de um novo caminho, diga-se, alvissareiro, porquanto auspicioso ao permitir uma maior liberdade aos magistrados na individualização da pena, em seu espectro mais amplo.

Neste eito, presentes os requisitos objetivos e subjetivos reclamados para a predita substituição, de rigor, a sua operação, substituindo-se, assim, a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, na proporção de uma hora por dia de condenação, cabendo, assim, no comenos oportuno, ser designada a entidade ou programa comunitário ou estatal, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, em conformidade com as suas aptidões, intimando-o, no momento adequado, a fim de dar-lhe ciência da entidade em que deverá cumprir sua pena, delineando-se, consecutivamente, os dias e horários em que serão realizadas as suas atividades, e ao pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser carreada à entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo juízo de execução.

Observe-se, por oportuno, que o termo inicial da execução da pena restritiva de direitos é o trânsito em julgado da sentença condenatória, em conformidade com o quanto estatuído no artigo 147 da Lei de Execução Penal.

Com o trânsito em julgado, em momento oportuno, ao Juízo das Execuções, para dar cumprimento aos cânones previstos no art. 149 da Lei de Execução Penal, observando-se, para tanto, o disposto no art. 147 da predita lei.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória, para o fim de condenar VINICIUS DAGOANI DE CARVALHO como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A multa terá correção monetária desde a data do crime. Como sublinhado acima, substituo a sobredita pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade e mais uma prestação pecuniária, nos moldes acima exarados. O devido delineamento das penas restritivas de direitos será feito pelo Juízo da Execução.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

O réu, diante do quantum de pena e regime imposto tem o direito de recorrer em liberdade, notadamente ao ser considerada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com suas devidas identificações, acompanhadas de cópia deste pronunciamento judicial; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; e d) adotem-se as cautelas legais, arquivando-se com baixa, após a certificação, se o caso, da ausência de pendências.

Diante das imagens colhidas, conforme relatório de serviço a fls. 124/129, no que atine ao aparelho de telefonia móvel, marca Motorola, modelo Galaxy J6, IMEIs 358473090586899 e 358474090586897, demonstrando a vinculação ao tráfico, decreto o seu perdimento, nos termos do artigo 63 da lei de drogas.

De outro bordo, com base no mesmo relatório de serviço, em relação ao aparelho de telefonia móvel, marca Samsung, modelo Galaxy J6, IMEI 357109099900274, o qual não pôde ser analisado, não havendo demonstração de vinculação com o tráfico, com o trânsito em julgado, não havendo mais interesse ao processo, o aparelho de telefonia móvel poderá ser restituído ao seu proprietário, dès que provada a propriedade por documento idôneo.

No concernente ao valor apreendido, considerando-se que, em juízo, a testemunha, como, também, o réu aludiram ao valor de R\$30,00 relacionado ao entorpecente comercializado, tendo-se em conta a apreensão de R\$51,30, conforme auto de apreensão e exibição (fls.13/14), mister decretar o perdimento, tão somente, do valor de R\$30,00, determinando, por seu turno, que a serventia observe o quanto preconizado no artigo 63 e seus respectivos parágrafos.

A sua vez, não tendo sido demonstrado que a quantia sobejante se trata de valor oriundo do tráfico, o que não pode ser presumido, após o trânsito em julgado, de rigor a restituição dos valores sobejantes ao seu titular.

Com o trânsito em julgado, havendo amostras guardadas para contraprova, observe-se, por necessário, o quanto estatuído no artigo 72 da Lei de Drogas, certificando-se nos autos.

P.I.C.

Jales, 01 de fevereiro de 2022.

Fábio Antonio Camargo Dantas

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA